

0011030-73.2022.8.26.0224

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Vera Lúcia Calviño de Campos

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... a fornecer a senha, ou então, sendo vítima de furto ou apropriação indébita, a mesma lhe foi tirada mediante fraude ou simulação, tudo isso com prévia comunicação. (Apelação Cível nº 2012224156 (19249/2012), 1ª Câmara Cível do TJSE, Rel. Maria Aparecida Santos Gama da Silva. unânime, DJ 11.01.2013)"

"CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTO DE COMPRAS E SAQUE NÃO REALIZADO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara do Juizado Especial Cível

RUA DOS CRISÂNTEMOS, Nº 29, Guarulhos-SP - cep 07091-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0011030-73.2022.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0011030-73.2022.8.26.0224

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Durval Ribeiro de Albuquerque

Requerido:

Banco do Brasil S/A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vera Lúcia Calviño de Campos

Vistos.

Dispensado o relatório pelo art. 38 da Lei nº 9.099/95.

DECIDO.

De inicio, afasto a preliminar de falta de interesse de agir, pois o a tese autoral fundada na alegada má prestação de serviço do banco não diz respeito aos pressupostos processuais de condições de ação, antes, confunde-se com o mérito, e com ele será analisado.

No mesmo fundamento, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada em contestação, reiterando que a questão relativa à possibilidade ou não de responsabilização civil da ré (fundado em alegada falha na prestação de serviço da ré), também não diz respeito a condições da ação, mas com o mérito.

Portanto, passo ao julgamento do mérito da ação.

O requerido não formulou qualquer proposta para acordo, o que permite concluir que a audiência de conciliação, dispensada por decisão normativa deste Juízo (fls. 23), realmente era desnecessária, inexistindo, por conseguinte, qualquer nulidade em sua

supressão.

A lide versa sobre questões de direito e de fato, estas provadas por documentos, permitindo seu julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, com o qual as partes não se opuseram.

No mérito, o pedido inicial é procedente.

Com efeito, é de se reconhecer que a relação jurídica material, deduzida na petição inicial, enquadra-se como relação de consumo, nos termos do § 2º, do artigo 3º, da Lei 8.078/90, sendo a responsabilidade do fornecedor de ordem objetiva, nos termos da Súmula 297 do STJ, e ADIn nº 2591, DJ 16.06.06.

Portanto, cabe ao consumidor demonstrar apenas que sofreu um prejuízo em decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor. Nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 a responsabilidade contratual da ré é objetiva, e apenas poderia ser desconsiderada se ficasse caracterizada uma das hipóteses do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

Entretanto, nada indica que o dano decorreu de culpa da parte autora, única causa que afastaria a responsabilidade civil do requerido, que não se exime de indenizar o dano decorrente de culpa de terceiro, pois tem o dever de prestar serviços com segurança que impeça fraudes.

Pelo que se depreende da petição inicial, da emenda e dos documentos que as acompanham, trata-se do conhecido "golpe do defeito no veículo", que consiste em ser a pessoa abordada por um ou dois indivíduos que insinuam defeito no veículo da vítima, um deles sempre se diz mecânico e se prontifica a "consertar" o problema, geralmente cobrando bem barato pelo "conserto", que ao ser pago na maquininha de cartão do meliante, geralmente ocorre falha no pagamento na primeira vez, o que leva a vítima a digitar sua senha mais de uma vez. A vítima vai embora achando que tudo está normal, para tempos depois se deparar com saques ou compras seguidas até esgotar seu limite ou saldo.

No caso apresentado pelo autor, com algumas variantes, demonstra que no dia dos fatos (07/03/2022, às 10h30min), a segunda pessoa que estava com o meliante foi embora, e o autor se prontificou a ligar para compra da peça, porém, o meliante ficou desconfiado e levantou sua blusa para demonstrar ao autor que estava armado, em seguida pediu o cartão do autor, que entregou diante da ameaça e digitou sua senha uma vez para o pagamento.

Aduz o autor que, ao sair daquela situação, foi até o banco réu para fazer o bloqueio, quando descobriu que os meliantes conseguiram fazer seis compras, no valor total de R\$9.710,84, sendo quatro a débito em sua conta corrente e uma a crédito em seu cartão de crédito (Compras a débito 07/03/22, às 11:15, R\$900,00 - MP FATURAMENTO; 07/03/22, às 11:15, R\$3.500,00 - MP FATURAMENTO; 07/03/22, às 11:16, R\$1.650,00 - MP FATURAMENTO; 07/03/22, às 11:17, R\$2.200,00, MP FATURAMENTO), (Compras a crédito 07/03/22, R\$960,84 2 parcelas de R\$ 480,42 - MP FATURAMENTO e 07/03/22, R\$500,00 - MP FATURAMENTO). Postula o autor pela devolução do valor.

Em contestação, o réu afirmou que não apresentou falha na prestação de seus serviços, alegando que houve regularidade nas transações, na medida em que foram feitas de forma presencial, mediante a apresentação do cartão, leitura do chip, no terminal do lojista e a aposição de senha, acrescentando, inclusive que, mesmo de posse do cartão, seria necessário a digitação da senha para compra, cujo uso e a guarda do cartão cabem exclusivamente ao cliente, no caso em tela, à parte autora; arguindo, por fim, que o caso se trata de fortuito externo e que, portanto, deve ser verificada a excludente de responsabilidade do fornecedor do serviço, incerta no art. o artigo 14, § 3º, I e II do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, em que pese as alegações do réu, é certo que não produziu nenhuma prova contundente que convença ter o autor efetivamente realizado, de forma consciente, as transações que impugnou, no valor total de R\$9.710,84, ocorridas no dia 07/03/2022 e registradas conforme extratos de fls. 17, 116 e 137.

Ora, dos extratos juntados pelo réu (fls. 137/146) é fácil verificar que o requerente não tem perfil de fazer compras a débito em valores tão elevados, nem várias compras em sequência, no mesmo dia e no mesmo estabelecimento, num intervalo

de menos de um minuto. Logo, essas transações, em valores superiores ao perfil do autor, e reiteradas no mesmo dia, no mesmo estabelecimento, em intervalo de menos de um minuto, deveriam levantar suspeitas junto ao réu, considerando-se o perfil de compras a débito comumente realizadas pelo consumidor.

Também as compras feitas no cartão de crédito do autor, ainda que em valores condizentes com seu perfil para compras a crédito, poderia igualmente ter levantado suspeitas, posto que foram seis compras num só dia, em um mesmo estabelecimento. Ora, como pôde o banco réu ter aprovado diversas compras à débito em seguida, num intervalo de menos de um minuto entre uma e outra, e ainda mais duas compras a crédito no mesmo estabelecimento, sem levantar nenhuma suspeita de tais transações? É evidente, portanto, que o requerido, no mínimo, cometeu grave falha em seu sistema de segurança em relação à autorização para a prática das referidas transações. Isso porque se o requerido tivesse monitorado o perfil do autor, saberia quanto ele costuma gastar no cartão de débito em um só dia, bem como a crédito, e, uma vez ultrapassado o limite razoável, teria bloqueado seu cartão, ainda que momentaneamente, até conseguir fazer contato com ele, a fim de confirmar que, efetivamente, era ele quem estava realizando, consciente e voluntariamente, as compras a débito. O mesmo raciocínio se aplica à repetição de pagamento ao mesmo estabelecimento no mesmo dia.

Ademais, é inimaginável que alguém com a descrição do autor (aposentado com 79 anos de idade), que recebe como proventos valores em torno de R\$7.000,00, vá gastar em um só dia o valor de R\$9.710,84, realizando quatro operações de compras a débito no mesmo estabelecimento, repita-se em intervalo de menos de um minuto, e, duas à crédito no mesmo estabelecimento, sem que o réu desconfiasse de tais transações, tendo ainda as autorizado!

Portanto, é evidente que o requerido contribuiu, por grave falha em seu sistema de controle de volume de transações, para os danos suportados pelo autor.

Por fim, considerando que é absolutamente impossível para o autor a prova de fato negativo (que não realizou, de forma consciente, as transações impugnadas), deveria o réu ter produzido um mínimo de provas que convencesse que não houve defeito do serviço bancário.

Pois bem, instado a produzir tais provas, conforme determinação de fls. 152, que inverteu o ônus da prova, o réu carreteou ao processo, extratos das transações bancárias, das quais se permitem verificar que as quatro compras a débito foram feitas em um só estabelecimento, num intervalo de dois minutos, o que claramente demonstra a falha do banco em não levantar suspeita do volume dessas transações em pouco tempo, num mesmo estabelecimento.

Ademais, embora tenha o banco réu fornecido no nome do estabelecimento em foram efetuadas as compras, não informou seu CNPJ, nem o endereço de tal estabelecimento, eis que diante de tal informação, poder-se-ia incluir tal estabelecimento no polo passivo.

Por fim, o réu não comprovou que seu setor anti-fraude fez contato com o autor para confirmar a autoria das transações, antes de autorizá-las, o que leva a conclusão clara de que de fato o banco falhou em seu sistema de segurança.

Por isso, não é possível entender que o autor facilitou o acesso a seu cartão e senha bancários por terceiros, como supõe o réu, eis que ele confessa que, após ameaça de arma de fogo, digitou sua senha uma vez somente, para pagamento do alegado conserto em seu veículo. Dessa forma, é possível que o fraudador tenha inserido o cartão do autor em sua máquina para confirmar o pagamento de R\$60,00, tendo o autor apostado sua senha apenas uma vez, porém, em verdade, a máquina estava fraudada, copiou os dados do cartão e a senha, registrando valores de pagamentos diversos, uma vez que o horário das compras coincide com o horário do ocorrido, conforme Boletim de Ocorrência registrado (fls. 6).

As provas indicam, com segurança, que as transações impugnadas realmente foram realizadas por ação de terceiro, que, mediante ameaça de arma de fogo e fraude, obrigou autor a digitar sua senha na máquina de cartão uma, possibilitando compras a débito e a crédito em valores elevados, o que torna nulas as transações impugnadas nesta ação, já que foram realizadas sem o consentimento livre da consumidora.

Nesse sentido, em casos análogos, são os seguintes acórdãos:

"SEQUESTRO RELÂMPAGO. SAQUES E COMPRAS COM CARTÃO BANCÁRIO E DE CRÉDITO. FALHA DO SERVIÇO. CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA. OCORRÊNCIA TAMBÉM DE DANOS MORAIS. DESCASO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MAIS DO QUE MERO ABORRECIMENTO. VALORES BEM ARBITRADOS PELO JUIZ "A QUO". PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Recurso Inominado nº 0001925-97.2014.8.26.9004, 2ª Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais/SP, Rel. Cláudio Salvetti D'Ângelo. j. 12.11.2014)."

"CIVIL E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SAQUE INDEVIDO NA CONTA-CORRENTE DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA. CARTÃO MAGNÉTICO BANCÁRIO. USO DE SENHA PESSOAL... O cliente bancário só se isenta da responsabilidade pelos saques realizados nos caixas eletrônicos quando for vítima de roubo ou dos chamados sequestros relâmpagos, nos quais é obrigado a fornecer a senha, ou então, sendo vítima de furto ou apropriação indébita, a mesma lhe foi tirada mediante fraude ou simulação, tudo isso com prévia comunicação. (Apelação Cível nº 2012224156 (19249/2012), 1ª Câmara Cível do TJSE, Rel. Maria Aparecida Santos Gama da Silva. unânime, DJ 11.01.2013)"

"CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTO DE COMPRAS E SAQUE NÃO REALIZADO. AFIRMATIVA DE OCORRÊNCIA DE ROUBO. AUSÊNCIA DE PROVA DO USO PELO TITULAR. UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE NÃO INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES SOB PENA DE MULTA. 1. Alegado que houve compras e saque a sustentar cobrança do cartão de crédito, compete ao fornecedor do serviço o ônus da prova. Cabível a inversão do ônus da prova do fato constitutivo do direito (artigo 6º, VIII, CDC), o que, no caso, decorre da lei, na responsabilidade pelo fato do serviço (artigo 14, CDC), conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção). Ademais, o consumidor não teria a possibilidade de demonstrar que não usara o cartão de crédito para as compras e o saque questionado. 2. O caso é de defeito na prestação do serviço, pois "Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto" (REsp 1.058.221/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma). Já a eventual fraude por terceiro constituiu caso fortuito interno que não exclui a responsabilidade do fornecedor porque se liga aos riscos do empreendimento, de modo que, ocorrido durante a prestação do serviço, não importa saber o motivo que determinou o defeito, sendo responsável o fornecedor ainda que oriundo de fato imprevisível e inevitável. 3. Os comprovantes das compras não vieram aos autos para o fim de respaldar o uso do cartão de crédito pelo recorrido, e não por terceiro. 4. O recorrente não exibiu prova de que o recorrido foi o responsável pelo saque realizado em sua agência bancária, tal como imagens de câmeras de segurança. 4.1. Ressalte-se que os terminais eletrônicos são colocados à disposição dos clientes também no interesse das instituições financeiras, não sendo plausível aceitar, por outro lado, que o fornecedor de serviço bancário permita a ação de fraudador no interior da sua agência ou posto de atendimento. Se assim o permite, evidente a falha na prestação do serviço porque não propicia a necessária segurança ao consumidor. 4.2. Não há prova de que o consumidor fornecera sua senha para viabilizar o saque por terceiro, o que, igualmente, denota a falha do sistema de informática do fornecedor. Aliás, se o fornecedor alega culpa exclusiva do consumidor porque não adotou precauções com a guarda de seus documentos, facilitando a captura de seus dados, deve demonstrar que apenas a entrega de algum documento viabilizou saque na conta, e não a possibilidade de acesso à senha do cliente por conta do sistema de informática falho. Precedente: ACJ 2005.01.1.007552-4, Rel. Juiz Jesuino Rissato, 2ª TRJE/DF. 5. Em harmonia com o artigo 52, inciso V, da Lei nº 9.099/95, o artigo 461,

parágrafo 5º, do Código de Processo Civil permite ao juiz impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 6º, do mesmo dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de recurso inominado sobre a exorbitância no arbitramento, antes de embargos à execução, inclusive porque a multa poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor máximo estabelecido inicialmente pelo juiz. 6. Recurso conhecido e não provido (art. 46 da Lei nº 9.099/95). 7. Condena-se o recorrente, vencido, no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R\$ 300,00 (trezentos reais). (Processo nº 2011.03.1.027842-5 (601617), 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Fábio Eduardo Marques. unânime, DJe 06.07.2012)."

"DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS ORIUNDOS DE COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. MOVIMENTAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. CONSUMIDOR VÍTIMA DE SEQUESTRO RELÂMPAGO. CONTESTAÇÃO DOS DÉBITOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA SUA EFETIVAÇÃO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO E COMPROVANTES DE COMPRAS EFETIVADOS PELO AUTOR. Ônus da prova competia ao banco apelado, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade do banco apelado, que exerce atividade lucrativa e assume os riscos pelos danos provocados por esta atividade. Inexigibilidade do débito reconhecida. Negativação indevida do nome do autor. DANO MORAL. Caracterizada a responsabilidade do requerido pelos danos morais. Valor da indenização fixado em R\$ 10.000,00 e que deve ser mantido, pois bem quantifica os prejuízos causados. Sentença mantida. Recurso não provido. (Apelação nº 1001344-36.2014.8.26.0704, 13ª Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Heraldo de Oliveira. j. 10.12.2014)."

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM DANO MORAL. Autora (ora recorrida) que foi vítima de "sequestro relâmpago", tendo os agentes sacado R\$ 500,00 de sua conta-corrente do Banco do Brasil e adquirido produtos nas lojas World Tennis no valor de R\$ 1.149,98. Boletim de ocorrência, reclamação aos requeridos c extratos bancários apresentados (fls. 11/17). Boa-fé da recorrida. Responsabilidade objetiva do recorrente (teoria da atividade). Artigo 927 do Código Civil. Relação de consumo. Prova da regularidade do "saque" que competia à Instituição Financeira (artigo 14, § 3º do CDC). Inversão do ônus probatório. Recorrida que é titular de seguro de cartão de crédito. Abusividade da cláusula que determina a exclusão da cobertura em casos de transações realizadas com base na função débito dos cartões de débitos (artigo 51, inciso 4º do CDC). Ação parcialmente procedente. Condenação do Banco do Brasil ao pagamento da quantia de R\$ 500.00 e da World Tennis do valor de R\$ 1.149,98. Recurso desprovido. (Recurso Inominado nº 0612678-67.2011.8.26.0016, 2ª Turma Cível Extraordinária do I Colégio Recursal dos Juizados Especiais/SP, Rel. Egberto de Almeida Penido. j. 10.04.2012, unânime, DJe 25.04.2012)."

De outro lado, convém argumentar que ao possibilitar que o consumidor faça compras e saques, a débito e a crédito, com um cartão magnético que contém a senha gravada no chip, o requerido criou uma facilidade que mais atende a seus próprios interesses financeiros, do que ao usuário de seus serviços. Isso porque, se não existisse a tecnologia do cartão magnético, as pessoas seriam obrigadas a utilizar dinheiro para pagamento de compras e, com isso, o réu não lucraria com as tarifas que cobra dos comerciantes a cada pagamento feito com cartão de crédito. Portanto, ao introduzir tecnologia que facilita transações a crédito e a débito, reduzindo seus custos e aumentando seus lucros com as tarifas que cobra dos comerciantes, o réu estabeleceu serviço que envolve risco, que deve assumir, sem prejuízo ao consumidor.

O prejuízo material suportado pelo autor é de R\$9.710,84, valor total do desfalque ocorrido em sua conta bancária e cartão de crédito em 07/03/2022, por falha do setor de segurança do réu.

Considerando que restou evidente a existência de defeito no serviço prestado pelo réu, se obriga, nos termos do art. 14, do CDC, a cancelar os lançamentos indevidos, bem como a restituir o valor de R\$9.710,84 ao autor. Todavia, para completa reparação, o valor deve ser atualizado pela correção monetária e acrescido de juros

remuneratórios de 0,5% ao mês, contados desde o evento, sem prejuízo dos juros de mora, nos termos do art. 404 do Código Civil.

ANTE O EXPOSTO, julgo PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação movida por DURVAL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE contra BANCO DO BRASIL S/A para condenar o réu a restituir ao autor a quantia de R\$9.710,84 (nove mil, setecentos e dez reais e oitenta e quatro centavos), atualizada pela correção monetária, de acordo com os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, e acrescida de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, ambos contados a partir do evento danoso (07/03/2022), tudo acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados desde a citação (15/08/2022), declarando extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Isenção de custas e de honorários advocatícios nessa fase, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Eventual recurso deverá ser interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, acompanhado das razões e do pedido do recorrente, que deverá efetuar, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, o preparo do recurso, consistente no pagamento de todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma dos artigos 42, §1º e 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. (despesas postais com citação e intimação; despesas de diligências dos Oficiais de Justiça; taxa judiciária equivalente a 1% do valor da causa somado a 4% do valor fixado na sentença, observado o valor mínimo de 5 UFESPs para cada parcela, na forma do artigo 2º, parágrafo único, III e IX, e artigo 4º I, II e §1º, da Lei Estadual nº 11.608/03, etc.).

Transitada em julgado, aguarde-se provocação do interessado por três meses, e, decorrido esse prazo, arquivem-se.

P.I.C..

Guarulhos, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA